

1500116-54.2022.8.26.0585

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/07/2022

...

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

1ª Vara

Av. Presidente Vargas 1-31, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500116-54.2022.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500116-54.2022.8.26.0585 - Feito nº 2022/001086

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO RICARDO PEREIRA DOS ANJOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, tombado sob o nº 2124453/2022, ofereceu denúncia em face de FLAVIO RICARDO PEREIRA DOS ANJOS, devidamente qualificado às fls. 29, dos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 06/05/2022, por volta das 22h30, na Av. Presidente Vargas, 207, nessa cidade e Comarca, FLAVIO RICARDO PEREIRA DOS ANJOS estaria vendendo e guardando, para entrega a consumo de terceiros, duas porções de Cannabis sativa L., pesando 15 gramas, e três porções de cocaína, pesando 204 gramas, drogas capazes de causar dependência física ou química, sem autorização legal ou regulamentar.

Realizada audiência de custódia, após a entrevista do autuado e manifestação do ilustre representante do Ministério Público e da nobre Defesa, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em flagrante do denunciado em prisão preventiva na data de 07/05/2022 (fls. 70-77).

Notificado (fls. 120), o acusado ofertou defesa prévia, ocasião em que requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 124-134).

O i. Representante do Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do acusado e requereu o recebimento da denúncia (fls. 140-143).

A denúncia foi recebida em 03/06/2022, ocasião em que foi rejeitada a hipótese de

absolvição sumária e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. Com fundamento no artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022 e Comunicado CG nº 284/2020, que autorizou a realização das audiências por videoconferência ou mistas em todas as matérias, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams (fls. 145-150).

O réu foi regularmente citado (fls. 177).

Laudos de exame químico de entorpecente acostados (fls. 186-188 e 189-191).

Prosseguiu-se, então, à fase instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico para o descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, ainda, por benefícios no tocante à pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, não há falar em prova ilícita ou ilegítima.

A regularidade da abordagem realizada pelos agentes policiais sobre o acusado está demonstrada nos autos. A justa causa estava patente: o acusado trafegava na via pública, em um táxi e sobre ele pendiam denúncias de tráfico na Vila Esperança, donde se conclui que, responsável a Polícia Militar pelo policiamento ostensivo das cidades brasileiras, era, de rigor, a abordagem de Flávio Ricardo, o qual encontrado na posse de grande quantia monetária (R\$ 2.364,00 em cédulas diversas cuja origem não fora comprovada nos autos, uma vez que os documentos de fls. 135-137 demonstram que o acusado auferia renda mensal média bem inferior) e um aparelho celular em sua posse, além uma porção de maconha e duas de cocaína, todas embaladas individualmente e prontas para o comércio (localizadas no local onde estava sentado, no interior do veículo).

Assim, a abordagem do denunciado, a princípio, fora legítima. É da natureza do trabalho da polícia militar receber denúncias anônimas frequentes por usuários de drogas a respeito dos traficantes locais.

Naquela altura, o investigado estava em via pública, durante a noite, no banco do passageiro de um táxi vindo, justamente, do bairro onde, para a polícia, traficaria. A abordagem pessoal do denunciado, feita a partir de fundadas suspeitas que recaíam sobre as atividades desempenhadas por Flávio, não fora desarrazoada ou descompensada.

Finalmente, Flávio já havia sido denunciado e processado criminalmente por tráfico de drogas. Ainda que absolvido, é de supor que, para o Ministério Público e para os órgãos repressivos de persecução penal, Flávio poderia estar envolvido com delitos relacionados a drogas, o que fundamenta ainda mais as razões de sua abordagem.

Com relação ao ingresso na residência, determina o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Neste sentido inclusive o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 603616, com repercussão geral reconhecida, e, por maioria de votos, que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Assim, por ser o crime de tráfico de natureza permanente, desnecessária a necessidade de mandado de busca e apreensão para a entrada dos policiais na residência do réu, de modo que a situação de flagrância perdura-se no tempo enquanto o acusado estiver na posse da substância entorpecente.

Dessa forma, ainda que considerada a hipótese de que os policiais tenham adentrado o imóvel sem o consentimento do acusado, havia justa causa para o ingresso na residência do acusado em razão da prévia localização de drogas na posse do acusado

aliada às circunstâncias da apreensão (que comprova a materialidade do delito de tráfico), eis que motivada pela existência de indícios prévios em relação ao acusado, consubstanciados em informações do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas.

No mérito, trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de FLAVIO RICARDO PEREIRA DOS ANJOS pela prática do fato delituoso disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De fato, assiste razão ao Ministério Público.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fls. 05-06), boletim de ocorrência (fls. 07-11), auto de exibição e apreensão (fls. 32-34), auto de constatação da natureza tóxica (fls. 30-31), laudo pericial de recortes plásticos, no qual foi constatado a presença de cocaína (fls. 192-194) e laudos de exame químico de entorpecente (fls. 186-188 e 189-191), que atestaram que as substâncias detectadas se tratava de Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, que são de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado Flavio Ricardo Pereira Dos Anjos.

Inquirida, a testemunha JORGE PAULO DE LIMA PAES, policial militar, relatou que "Na data dos fatos, estava em policiamento de rotina e perto do cruzamento que dá acesso à Vila Martins, passou um táxi em que estava o Flávio, como passageiro, sentado na frente do veículo, ao lado do condutor. Flávio era já conhecido dos meios policiais por tráfico de drogas e pendiam denúncias sobre ele traficar ali na Vila Esperança: sim, eram denúncias anônimas reservadas a nós feitas por usuários. Sabíamos onde ele morava. Esperamos que eles entrassem na Avenida, local mais seguro e mais claro, porque ali perto havia um matagal, e, aí perto do fórum, o abordamos. No táxi, em busca pessoal, encontramos R\$ 2.364,00 em cédulas diversas e um aparelho celular em sua posse. De resto, com ele, mais nada. No veículo, no local onde ele estava sentado, atrás do extintor, havia uma porção de maconha (embalada em plástico-filme transparente) e duas de cocaína (uma em plástico branco, outra em fita isolante preto). Geralmente, isso significa que a droga estava pronta para venda, estava bem embalada. Ele alegava que os entorpecentes seriam para seu uso e teriam sido adquiridos na Vila Martins, de onde ele viria. Quando indagado, Flávio mentiu sobre seu endereço de origem. O taxista nos confirmou que teria buscado o rapaz no endereço de que tínhamos ciência e, questionado, ele admitiu que residia onde sabíamos. Ele morava na casa com outro irmão, não presente na abordagem, e ele nos autorizou o ingresso na residência e acompanhou integralmente as buscas: em um hack, havia uma porção de maconha embalada, na sala; interessante que encontramos restos de fitas prestas vazias, vários recortes de plástico no cesto do lixo do banheiro (restos de plásticos por certo usados para embalar drogas). Finalmente, no quarto do rapaz, enrolado em um cobertor, havia sacola plástica com grande quantidade de cocaína embalada e pronta para venda. Imediatamente, ele admitiu ter comprado fiado as drogas em Bataguassu/MS por R\$ 22.000,00, para arcar com uma dívida de drogas em oportunidade prévia em que havia sido preso. Admitiu o tráfico, já teria vendido grande parte dos entorpecentes e deveria ainda R\$ 6.000,00. Sim, eram fitas isolantes semelhantes aos encontrados nas drogas do carro. Cabo Silveira e Subtenente Adriano. Sim, advertimos sobre o direito ao silêncio, não gravamos a advertência por não vermos necessidades. As denúncias anônimas não foram reportadas por mim à autoridade policial ou ao Ministério Público. Sim, o taxista estava perto, ele deve ter visto a apreensão de drogas. Não sei informar, a autoridade policial que dispensou o taxista. No local da abordagem, o taxista disse que sempre pegava o réu nesse endereço, que estava apenas fazendo suas corridas. Ele foi à delegacia sim, ele chegou lá na frente e foi liberado. Tudo foi apresentado ao delegado".

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar GILBERTO BARBOSA SILVEIRA, o qual complementou: "Em patrulhamento por Epitácio, avistamos Flávio de passageiro, no banco da frente, em um táxi. Logo após, realizamos a abordagem: fiz a busca pessoal em Flávio e localizei consigo R\$ 2.364,00 e um celular. Cabo Paes fez a vistoria e, no assoalho do veículo, duas porções de cocaína e uma de maconha foram encontradas. Indagado, Flávio alegava que as drogas eram para seu uso e o

dinheiro era pagamento recebido por seu trabalho no frigorífico. Ele alegava que em sua casa havia apenas uma porção de maconha. Ele mentiu sobre seu endereço. Quando afirmamos que sabíamos que ele morava na Rua Hungria, última rua da Vila Martins, ele confirmou. Fomos até lá, ele autorizou nossa entrada em sua residência: fita isolante em cima da mesa, recortes de sacolas plásticas no lixo do banheiro e maconha sobre o hack; no quarto havia grande porção de cocaína. Ele confessou que traficaria para pagar dívida de drogas perdidas em prisão anterior que sofrera. Admitiu haver pago R\$ 22.000,00 pelas drogas e já teria vendido grande parte dos entorpecentes. Apareceu uma senhora, não sei se parente dele, que morava ao lado, mas ela não nos falou nada. Ele foi qualificado e o dispensamos próximo à DP. A gente conversou com o delegado e não havia precisão do taxista esperar na DP. A respeito desse vídeo, nem sei se o Cabo Paes o entregou ao delegado. Não, ele autorizou: ele deixou filmar, ele nos viu filmando. Sim, passamos a ele todas as medidas: que ele tinha direito a advogado, que poderia ficar em silêncio. Três policiais. Dessa equipe, não. Subtenente Adriano, Cabo Paes e eu. Não, ele passou o endereço errado no início. Depois, ao passar o endereço correto, ele admitiu ter uma porção de maconha na sala, perguntamos se poderíamos ir pegá-la, ele autorizou. Perguntado se poderíamos vistoriar outros cômodos, ele autorizou".

ELIZABETH NAIR DA SILVA SANTOS (informante do juízo): "Sou tia. Não estava. Estava na minha casa, que fica ao lado. Assim que os policiais chegaram, meus cachorros deram alarme e meu marido me acordou. Levantei e vi os policiais já dentro da viatura com ele. Ainda não tinham entrado na casa. Fiquei observando. Quando fui dar ré e entrar, ele gritou meu nome, fui ver onde ele estava, ele já tinha entrado dentro da casa. Pedi que me deixassem entrar, não permitiram minha entrada, dizendo que era um rapaz de maior que estaria ali e que era para eu deixá-los realizar seu trabalho. Eu deixei. Na hora em que sai, vi que todos estavam em silêncio dentro da viatura, não dava para ouvir nada. Não ouvi se Flávio tinha autorizado ou não (o ingresso dos policiais na casa). Quando fui entrar de novo em minha casa, Flávio gritou e os policiais já estavam dentro da casa dele. Acho que foi um grito do tipo 'tia, me socorre que os policiais estão me abordando'. Trabalha no frigorífico de Bataguassu tem, mais ou menos, quase dois anos. Eram quatro da madrugada havia movimento em sua casa (chuveiro, de banho e de trabalho) e três e pouco da tarde ele voltava".

Interrogado, o acusado FLAVIO RICARDO PEREIRA DOS ANJOS negou a prática delitiva, dizendo "Quero falar, senhora. Sim, estava com esse dinheiro comigo. Era proveniente do meu trabalho e das operações que faço na internet com gráfico de operações binárias. Não pago aluguel, moro na casa da minha tia. Compro comida. Uso o dinheiro do meu trabalho e da operação binária que faço na internet. Porque eu ia à casa da minha namorada e no dia seguinte eu iria à casa da minha mãe, onde olharia uma moto de um rapaz que mora ali perto, para fazer a compra. Não, senhora, desconheço essa droga. Não tinha drogas comigo no táxi. Não sei informar de quem era. O taxista: Sandro não sei o segundo nome dele não, só o primeiro. Não sei informar, senhora, só tinha o número dele salvo no meu celular. Desconheço essa droga também, senhora. Contra os policiais não tenho nada. Só que na outra vez, a droga não era minha, foi encontrada na minha casa, mas não era minha, eu estava dormindo, já expliquei tudo e já fui absolvido. Entre R\$ 100,00 a R\$ 200,00 por dia (ganho com operações binárias na internet): chamei minha tia devido à sensação de medo, porque eu só os tinha autorizado a irem comigo até minha casa, mas não a entrarem lá. Não me avisaram nada, não sabia que estava sendo gravado, tanto que deve dar para ver pelo vídeo que eu nem olho para a câmera".

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra do acusado se encontra em dissonância do conjunto probatório, em especial das testemunhas policiais militares que empreenderam as investigações e efetuaram a diligência de apreensão das substâncias.

Inicialmente, não há porque se desconfiar da palavra dos policiais militares, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a

sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. Tanto não é possível exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia.

Com relação aos relatos da informante do juízo, verifico que pouco contribuíram para o esclarecimento do ocorrido, notadamente porque não acompanhou toda a diligência, especialmente com relação ao momento da abordagem e da localização dos entorpecentes. Outrossim, por possuir proximidade com o réu, devem ser analisados com parcimônia, até porque, impossível averiguar a necessária imparcialidade para o depoimento.

No mais, frise-se que, na divergência existente entre os depoimentos das testemunhas, deve se dar preferência para o depoimento daquelas que não têm relação de parentesco com o réu, porquanto isentas.

Nessa toada:

"PROVA - Testemunhos conflitantes - Prevalência daqueles oferecidos por pessoas estranhas aos partícipes da cena criminosa - Condenação mantida.126 - No conflito de versões oferecidas por pessoas desinteressadas quanto à sorte da demanda, estranhas aos envolvidos na infração e por pessoas sentimental e afetivamente ligadas a um dos personagens, claro que as declarações das primeiras se haverá de conferir credibilidade maior." (RJDTACRIM VOLUME 2 ABRIL/JUNHO 1989 PÁGINA: 138 RELATOR:- CANGUÇU DE ALMEIDA).

Assim, como se verá a seguir, as provas não deixam dúvidas acerca do cometimento do delito pelo acusado.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal:

"A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

No mais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irrealidade.

Nada indica que os policiais tenham criado uma situação para acusar falsamente o acusado.

As testemunhas de acusação descreveram com riqueza de detalhes como se deram os fatos, sem qualquer elemento de contradição em seus relatos, de forma que, tratando-se de versão escusatória, cabia ao réu e à Defesa a sua demonstração de forma cabal e inequívoca, o que não fora feito nestes autos.

A presunção iuris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Nessa toada:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal . O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se

harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Há indícios plurais, múltiplos e unívocos a respeito da prática de tráfico pelo denunciado (quantia em dinheiro que estava em seu poder, durante o final-de-semana, à noite; ausência de comprovação da regular origem do dinheiro; encontrados na casa do denunciado pedaços de plásticos idênticos aos das drogas que estavam no táxi). Em síntese, a versão de que a elevada quantia em dinheiro seria fruto de seu trabalho lícito é absolutamente desarrazoada. Seu salário mensal, dos últimos três meses antes da abordagem, não somam a quantia apreendida.

Ainda, a tese de que trabalharia em gráficos de operações binárias pela internet é, a par de não demonstrada minimamente em juízo, sem qualquer estofo na realidade concreta brasileira.

Existe um nexos íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.

Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Com efeito, os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos: a variedade de entorpecentes apreendidas em poder do acusado (cocaína e maconha); a relevante quantidade e modo de acondicionamento dos entorpecentes (duas porções de maconha, pesando 15 gramas; duas porções de cocaína, embaladas individualmente e prontas para o comércio, pesando 8 gramas; e uma porção maior de cocaína, pesando 196 gramas, capaz de produzir em torno de 196 papelotes, uma vez que um papelote tem peso médio de 0,3g a 1,0 g); a tentativa de ocultação do entorpecente (o acusado dispensou os entorpecentes no veículo assim que visualizou a viatura policial); a apreensão de petrechos para embalar drogas (um rolo de fita isolante e uma sacola plástica com diversos recortes, contendo resquícios de entorpecentes); a questionável a origem financeira dos valores apreendidos (R\$ 2.364,00 apreendidos em poder do acusado), eis que nenhuma prova idônea foi trazida aos autos para comprovar sua licitude como já exarado; e a confissão informal do réu aos policiais que o prenderam revelam que se tratava sim da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, visando o consumo de terceiros.

E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias são favoráveis. Isso porque deixo de considerar, nesta fase de dosimetria, a fim de evitar "bis in idem", os critérios constantes do artigo 42, da Lei de 11.343/06, uma vez que tais circunstâncias serão consideradas na terceira fase de dosimetria.

Nesse sentido:

"[...] a Corte firmou o entendimento de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas em poder de um réu condenado por tráfico de entorpecentes apenas podem ser utilizadas, na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena, sempre de forma não cumulativa. Ressaltou-se, ainda, que a utilização em duas fases do cálculo da pena caracteriza, o bis in idem. Desse modo, cabe ao juiz sentenciante, de acordo com seu poder de discricionariedade, definir em qual momento da dosimetria da pena a circunstância referente à quantidade e à natureza da droga será utilizada, desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-se a ocorrência de bis in idem" (STF - HC: 121853 PR, Relator: Min. LUIZ

FUX, Data de Julgamento: 13/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: Dje-213 DIVULG 29-10-2014).

Destarte, considerando que o réu é tecnicamente primário e que todos os demais elementos são inerentes ao tipo penal, fixo as penas no patamar mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não vislumbro presente nenhuma circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase de cálculo penal, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

No entanto, em razão da variedade (cocaína e maconha) e do elevado poder deletério da cocaína, imponho uma redução na metade, totalizando 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nesse ponto, ressalto posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida." (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, excepcionalmente, verifico que o regime inicial aberto se mostra mais adequado, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da primariedade, conduta social, personalidade favoráveis, não obstante a alta lesividade da substância entorpecente apreendida.

E, pelos mesmos motivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação; e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser corrigida monetariamente, a partir da data dos fatos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR FLAVIO RICARDO PEREIRA DOS ANJOS, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas; e substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privação de liberdade; e prestação pecuniária em favor de instituição pública ou privada de destinação social no montante de um salário mínimo, a ser corrigido monetariamente, a partir da data dos fatos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Considerando o regime inicial fixado e que o acusado e que não mais estão

configurados os requisitos ensejadores da custódia cautelar do acusado com o encerramento da fase de instrução e pelo fato do acusado possuir residência fixa e atividade lícita (fls. 135-137), concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se, desde logo, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro não estiver preso.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração e diante da ausência de pedido.

Concedo ao sentenciado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita.

Considerando que foram apreendidos nos autos R\$ 2.364,00 (auto de exibição e apreensão de fls. 33-34), nos moldes do disposto no artigo 91, inciso II, "b" do Código Penal e no artigo 63, § 1º, da lei 11.343/06, declaro, após o trânsito em julgado, o perdimento dos valores (depósito judicial às fls. 95) em favor da União e o seu encaminhamento ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em virtude dos fundamentos utilizados nesta sentença.

Considerando que foram apreendidos nos autos um rolo de fita isolante e recortes plásticos diversos (auto de exibição e apreensão de fls. 33-34), os quais estão diretamente relacionados à prática delitiva, declaro o seu perdimento em favor da União e autorizo a destruição, dada à inexpressividade de seu valor econômico. Todavia, tendo em vista que não há provas da efetiva utilização do aparelho celular (auto de exibição e apreensão de fls. 33-34) na prática do delito, autorizo, após o trânsito em julgado desta sentença, a restituição do bem ao sentenciado ou à pessoa por ele indicada, mediante pedido expresso. Nos termos do artigos 122 e 123 do Código de Processo Penal, se não houver requerimento no prazo de 90 dias, a contar do trânsito em julgado, fica, desde já, declarado o seu perdimento e autorizado o leilão, a destruição do bem, ou ainda o recolhimento ao museu criminal, se houver interesse na sua conservação (artigo 516 das NSCGJ), mediante comunicação ao SENAD. Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Autorizo a incineração da substância entorpecente remanescente, guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º e § 2º, da Lei 11.343/06;

Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa, no prazo de 10(dez) dias.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se.

de Presidente Epitácio, 29 de julho de 2022

MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) MAGISTRADO(A), NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.